

1501945-54.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... Ele a princípio negou a prática do tráfico de drogas, mas no DP ele disse que estava como olheiro do tráfico e que o dinheiro era dele. Junto com o réu tinha mais um rapaz que não foi abordado. Tem certeza que foi o réu quem dispensou a sacola com as drogas. O local é um ponto de venda de drogas conhecido, e não tinha visto o réu no local antes.

Neste sentido foi o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501945-54.2021.8.26.0537 - Controle nº 2021/001481

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2273787/2021 - 02º D.P. DIADEMA, 20695456 - 02º D.P. DIADEMA, 2047/21/123 - 02º D.P. DIADEMA, 2273787 - 02º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Anderson Salviano da Silva

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

ANDERSON SALVIANO DA SILVA, qualificado às fls. 05 e 18/19, está sendo processado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 06 de outubro de 2021, por volta das 15h30, na Passagem Companheiro Edmundo, altura do nº. 50, bairro do Piraporinha, nesta cidade e comarca de Diadema, atuando previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, unidos em desígnios e divisão de tarefas para o fim comum, trazia com ele e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 100 porções contendo 83,7g da droga cocaína, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 09/10 e laudo de constatação

provisória de fls. 14/16, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls.38/41), o d. Advogado particular apresentou defesa inicial às fls.87/115. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 16/12/2021 (fls. 172/173) e certificada a notificação e a citação positiva do Réu a fl.79.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas comuns e interrogado o réu ao final. Encerrada a instrução sem requerimento de diligências, seguiu-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação da pena base acima do mínimo diante da quantidade e nocividade da droga cocaína, em que pese a confissão do acusado, concordando com a redução da pena no percentual da metade, mas não também por sua substituição pela pena restritiva de direitos, devendo ser fixado regime prisional semiaberto sem possibilidade de recurso em liberdade.

Já o d. Advogado reiterou o pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, com a atenuante da confissão, com o redutor da pena e sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime aberto e possibilidade de recurso em liberdade em virtude do tempo de prisão por este processo.
É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fls.09/10, nos laudos de constatação e no definitivo (fls.14/16 e 176/178), ambos positivos para a droga cocaína.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais militares (fls. 02/04) realizavam o patrulhamento ostensivo com as motocicletas M-24280 e - M24 284, pela Passagem Companheiro Edmundo, local notoriamente conhecido como ponto de venda de drogas, quando dois indivíduos desconhecidos ao notarem a presença da equipe, saíram correndo em desabalada carreira. Seguiram no encalço dos indivíduos, sendo que um deles, ora indiciado, jogou ao solo uma sacola plástica transparente que carregava em mãos, sendo que, após poucos metros, conseguiram realizar a abordagem. O segundo indivíduo logrou êxito em empreender fuga. Diante do exposto, realizaram o procedimento de busca pessoal, oportunidade em que foi encontrado no bolso da bermuda do indiciado a quantia de R\$ 10,00 reais. Ato contínuo, verificada a sacola plástica dispensada, encontraram em seu interior 100 (cem) papétes de uma substância de cor branca aparentando ser cocaína, todas embaladas e individualizadas. Indagado o indiciado a respeito dos fatos, negou estar traficando.

Sob o crivo do contraditório o policial Fernando José de Lima reiterou que haviam dois indivíduos na via. Assim que os viram, correram, e o réu jogou algo na via. Ele foi abordado. Voltou e pegou a sacola do chão e nelas estavam invólucros de cocaína e com ele dez reais. Ele a princípio negou a prática do tráfico de drogas, mas no DP ele disse que estava como olheiro do tráfico e que o dinheiro era dele. Junto com o réu tinha mais um rapaz que não foi abordado. Tem certeza que foi o réu quem dispensou a sacola com as drogas. O local é um ponto de venda de drogas

conhecido, e não tinha visto o réu no local antes.

Neste sentido foi o depoimento judicial do policial Itailson Santos, disse que estavam em patrulhamento quando dois indivíduos os viu e correram. O réu era um deles e quem dispensou uma sacola que depois viram que continha drogas, cem papalotes de cocaína, aparentemente. Reconhece o réu e não o tinha visto lá antes.

O réu, em solo policial (fl.05) confessou que se encontrava no local exercendo a função de olheiro do tráfico, sendo que recebia a quantia de R\$100,00 por dia para exercer tal função. Com relação ao outro indivíduo que conseguiu se evadir correndo, declarou não conhece-lo.

Em juízo o acusado confessou que estava mesmo no tráfico, mas como campana, como olheiro. Foi o outro rapaz quem jogou a sacola com as drogas. Não tem passagem policial e nunca foi preso antes. Estava precisando, pois sempre trabalhou, mas por causa da pandemia, ficou desempregado, e precisava se manter, seu aluguel e alimentação, e foi fazer isso, mas está arrependido.

Logo, o interrogatório com a confissão do acusado ainda que no sentido de estar trabalhando para o tráfico como "olheiro" e não como "vapor", não é prova única, pois veio corroborada pelos depoimentos dos testemunhos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária.

E nem se alegue haver somente os policiais como testemunhas porque no caso em tela inexistiu outra pessoa civil que pudesse servir de testemunha. Ademais, é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ e STF, HC 76.608-0.

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares trazer consigo e guardar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Afasto tese de estado de necessidade ou desemprego a justificar a conduta do réu, pois os bens jurídicos são desproporcionais, por se colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade, em detrimento do interesse individual, além de se tratar de crime de perigo abstrato. Também não há que se falar em estado de necessidade, pois não há provas nos autos de que o apelante passava por miserabilidade extrema a ponto de ter que violar a lei para sobreviver. A mera dificuldade financeira (ou desemprego) não autoriza ninguém a praticar delitos (TJSP, Apelação Criminal n.º 0006727-87.2004.8.26.0081, Rel. Caio Ferraz de Camargo Lopasso, 5.ª Câmara Criminal D.J.E., j. em 29.07.2011).

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaína), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido (fl. 78), são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia, de modo que a procedência do pedido é inarredável, ficando afastada a possibilidade de desclassificação para a figura do art. 37 da lei Antidrogas, pois os policiais afirmaram que não perderam o réu de vista e que foi ele quem dispensou a sacola contendo drogas e que, portanto, era ele quem trazia consigo e guardava as drogas, não se tratando de mero olheiro, como tenta fazer crer e não comprova como lhe competia o ônus dessa prova. Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito a não demandar aumento inicial na pena, assim como a quantidade do narcótico apreendido que não reputo excessivo, embora não seja pouco, às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base mínima: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes e sim a atenuante da confissão, ainda que parcial já que o réu tenta fazer crer ser mero olheiro, mas tendo sido utilizado o interrogatório como meio de prova de autoria para a fundamentação do presente decreto condenatório, milita em seu favor a atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Contudo, não se tem como reduzir a pena aquém do mínimo legal já fixada, consoante Súmula 231 do STJ. E anoto aqui que, se considerado pedido da Acusação de pena acima do mínimo legal em primeira fase por seu entendimento de excessiva quantidade de drogas, nessa fase a reprimenda tornaria ao mínimo legal, como já está.

Em terceira etapa, não concorrem causas de aumento de pena. Quanto ao privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, sendo hipótese de "tráfico privilegiado", o Réu faz jus ao beneplácito legal, porquanto seja primário (fls.63/65), mas a apreensão do dinheiro, ainda que apenas dez reais, provenientes da venda de drogas, porque prova contária não foi produzida, e também pela natureza da droga, cocaína, de alto poder viciante e degradante da saúde humana, opto pelo redutor de 3/5, totalizando 02 anos de reclusão e 200 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo atual tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

A teor do disposto nos artigos 33, do Código Penal, fixo o regime prisional semiaberto, considerando a quantidade da pena, mas também a preponderância da natureza e da quantidade da droga, não fixando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006. Ora, como já visto, foram cem invólucros de cocaína, bastante quantidade de droga, e de alto poder maléfico.

Cito jurisprudência acerca do regime prisional em casos que tais: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional. (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019).

Incabível a benesse do art. 44 do CP, não se mostrando suficiente nem eficaz à reprovação da conduta do agente, menos ainda socialmente recomendável sob pena de potencializar a sensação de insegurança e intranquilidade social, a merecer maior reprovabilidade a conduta, dado que viola mais intensamente o bem jurídico tutelado, somado ao elevado número de ocorrências de tal natureza conferindo constante desassossego à sociedade, a exigir firme repressão do Estado como forma de desestimular o crime, geralmente cometido graças ao nível de organização próprio daqueles que fazem do tráfico seu meio de vida.

Não bastasse isso, artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de

diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves .

Contudo, permito o recurso em liberdade dado o tempo de prisão por esse processo, acolhendo assim pedido da Defesa, considerando a detração penal. Expeça-se o necessário.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra ANDERSON SALVIANO DA SILVA, qualificado às fls. 05 e 18/19, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e o faço para condená-lo à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 200 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos.

O condenado poderá apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, em 100 UFESPS, por ter constituído Advogado Particular.

Decreto a perda de valores apreendidos nestes autos (fl. 79), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias, e em 60 dias as despesas processuais, sob pena de extração de certidões da Sentença para a Procuradoria Geral do Estado (dívida ativa).

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA